

1518673-93.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena com substituição por restritiva de direitos.. É o relatório. DECIDO. Uma vez encerrada a instrução, não existe prova suficiente nos autos da prática de tráfico de drogas, mas porte de drogas para uso próprio, impondo-se a desclassificação e o reconhecimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1518673-93.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226358/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 26855395 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2226358 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DE OLIVEIRA LIMA

Vítima:

Saúde Pública

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 18 de outubro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à gravação que acompanha o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. PEDRO FERNANDES CASTELO MACIEL.

B. Defesa: dr. FERNANDO LATORRACA, defensor público do Estado.

C. Acusado: JEFFERSON DE OLIVEIRA LIMA ausente.

D. Testemunhas: WELLINGTON TAYLOR HENRIQUE DOS SANTOS e GLAUCO DA SILVA LIMA.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: o MM. juiz decretou a revelia do acusado, que não foi localizado para ser intimado (fl. 110), nos termos do disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal.

4. OCORRÊNCIAS: Foram inquiridos os policiais militares WELLINGTON TAYLOR HENRIQUE DOS SANTOS e GLAUCO DA SILVA LIMA. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou JEFFERSON DE OLIVEIRA LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da lei n. 11.343/06. Recebida a denúncia, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. Seguiu-se a instrução probatória com inquirição de testemunhas. O acusado, revel, não foi interrogado. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com a imposição de regime inicial aberto para o cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa sustentou improcedência da denúncia com fundamento na fragilidade da prova e, de forma subsidiária, a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena com substituição por restritiva de direitos.. É o relatório. DECIDO. Uma vez encerrada a instrução, não existe prova suficiente nos autos da prática de tráfico de drogas, mas porte de drogas para uso próprio, impondo-se a desclassificação e o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28, da lei de drogas. O acusado, quando interrogado na fase policial, afirmou que portava as drogas para uso próprio e que trabalhava como servente de pedreiro, inclusive declinando o nome da empresa SIMPICO ENGENHARIA (fl. 15). A versão apresentada pelo acusado não é inverossímil e não foi infirmada nos autos. Em primeiro, a polícia civil não identificou o conteúdo das alegadas "anotações de venda de drogas". O laudo pericial requisitado para essa finalidade não foi apresentado, tendo sido consultado nesta data o sistema de laudos da polícia civil (fl. 26 e 114). Não há sequer uma fotografia nos autos dessas anotações. Os dois policiais militares inquiridos nesta audiência relataram que não presenciaram nenhum ato de traficância e, inclusive, suspeitaram de porte de arma. Nada relacionado com drogas. A abordagem ocorreu em um bairro populoso da periferia da capital, não se podendo reduzir todo o local a um "conhecido ponto de venda de drogas". A quantidade de droga não é incompatível com o consumo – menos de 60 gramas de maconha e menos de 10 gramas de cocaína. Não houve qualquer diligência policial complementar para investigação do alegado tráfico de drogas e nenhuma outra prova foi apresentada nos autos. Tudo está a evidenciar a inocorrência de tráfico de drogas, mas porte para consumo próprio, sendo forçosa a desclassificação da conduta atribuída na denúncia. E em se tratando de mero porte para consumo pessoal, impõe-se o reconhecimento da INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28, da lei de drogas, com a absolvição do acusado, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, da intervenção mínima, lesividade e, ademais, às garantias constitucionais da privacidade e da intimidade. A questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 635.659, com repercussão geral reconhecida e, até o momento, os três ministros que proferiram voto declararam, em maior ou menor extensão, a inconstitucionalidade desse dispositivo. O Ministro GILMAR MENDES votou no sentido de "declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de forma a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal". O Ministro EDSON FACHIN, em posicionamento mais restrito, votou no sentido de "declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343, sem redução de texto, específica para situação que, tal como se deu no caso concreto, apresente conduta que descrita no tipo legal tiver exclusivamente como objeto material a droga aqui em pauta <>". O Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, por sua vez, votou no sentido de declarar inconstitucional "a tipificação das condutas previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, que criminalizam o porte de drogas para consumo pessoal" e ainda apontou "parâmetro objetivo capaz de distinguir consumo pessoal e tráfico de drogas" em relação à maconha. A questão, evidentemente, será retomada com o voto dos outros ministros que compõem o Tribunal, mas, ao menos até o julgamento definitivo do recurso extraordinário com repercussão geral, é inescapável o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo em controle

difuso, o que faço em revisão de posicionamento anteriormente adotado. A criminalização do consumo de drogas é incompatível com os objetivos estabelecidos pela própria lei de drogas, que estabelece, logo em seus primeiros artigos, medidas de prevenção, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Longe de permitir a consecução desses objetivos, o tratamento do usuário como criminoso, e a consequente atuação do sistema de justiça criminal, incluídas as agências policiais, acarretam estigmatização, degradação e rompimento de vínculos comunitários, justamente o que a lei busca impedir. A possibilidade de imposição de pena, ainda que abrandada, não aproxima o usuário do tratamento; ao contrário, afasta-o, porque significa confissão de culpa criminal e sujeição à violenta atuação de órgãos de repressão. Se a criminalização (meio) está em confronto com os objetivos declarados da lei (fim), é forçoso reconhecer excesso legislativo por ofensa ao princípio da proporcionalidade. Nesse ponto, importante destacar a lição do Ministro GILMAR MENDES, em voto proferido nos autos do já mencionado RE n. 635.659/SP: "Nesse contexto, a tipificação penal de determinadas condutas pode conter-se no âmbito daquilo que se costuma denominar de descrição legislativa. Cabe ressaltar, todavia, que, nesse espaço de atuação, a liberdade do legislador estará sempre limitada pelo princípio da proporcionalidade, configurando a sua não observância inadmissível excesso de poder legislativo. A doutrina identifica como típicas manifestações de excesso no exercício do poder legiferante a contraditoriedade, a incongruência, a irrazoabilidade ou, em outras palavras, a inadequação entre meios e fins. A utilização do princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso no direito constitucional envolve, assim, a apreciação da necessidade e adequação da providência adotada. Essa orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal (Gesetzesvorbehalt) no princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt des verhältnismässigen Gesetzes), pressupõe não só a legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos, como, igualmente, a adequação dos meios para a consecução dos objetivos pretendidos e a necessidade de sua utilização. De um lado, a exigências de que as medidas interventivas se mostrem adequadas ao cumprimento dos objetivos pretendidos. De outra parte, o pressuposto de que nenhum meio menos gravoso revelar-se-ia igualmente eficaz para a consecução dos objetivos almejados. Em outros termos, o meio não será necessário se o objetivo pretendido puder ser alcançado com a adoção de medida que se revele, a um só tempo, adequada e menos onerosa. Com isso, abre-se a possibilidade do controle da constitucionalidade material da atividade legislativa também em matéria penal. Nesse campo, o Tribunal está incumbido de examinar se o legislador utilizou de sua margem de ação de forma adequada e necessária à proteção dos bens jurídicos fundamentais que objetivou tutelar." O grifo não consta no original. Além de clara ofensa à regra da proporcionalidade, o tratamento do usuário de drogas como criminoso envolve um juízo exclusivamente moral, que é incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana e representa indevida ingerência estatal na esfera da intimidade, que tem evidente proteção constitucional. Não se trata de punir uma grave violação a um direito alheio, que é a essência do direito penal, mas um comportamento meramente inadequado, incorreto e até censurável, contudo, sem relevância jurídica para fins de política criminal. Por fim, o argumento de ofensa à saúde pública ao qual se apegam os defensores da criminalização é falacioso, porque o Estado tolera o consumo de outras drogas, como o álcool e o tabaco, a um custo humano e financeiro muitíssimo superior ao despendido com drogas ilícitas. A atuação do Estado em relação a drogas ilícitas não deve diferir das medidas desestimuladoras atualmente adotadas em relação ao álcool e ao tabaco, como publicidade negativa, regulação e até tributação, de toda forma sem utilização de órgãos de repressão penal, já que nesta área encontra-se o Estado jungido aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade. A criminalização do usuário de drogas, em verdade, revela hipocrisia e moralismo desmedidos, que ofendem diversos preceitos constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana, na perspectiva de garantia da personalidade e proibição de (des)proporcional ingerência estatal na esfera privada da cidadania. Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE a DENÚNCIA para o fim de ABSOLVER J.D.O.L., qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento, no artigo 386, inciso III, do

Código de Processo Penal. Autorizo a destruição das drogas e dos objetos apreendidos nos autos. Comunique-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público informou a intenção de RECORRER, enquanto a defesa técnica o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Recebo o recurso. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para a apresentação das razões e, em seguida, à Defensoria Pública do Estado para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as anotações necessárias. Sem prejuízo, expeça-se edital de intimação da sentença para o acusado revel. Saem os presentes intimados."

A gravação da audiência foi importada para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontra-se vinculada a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.